

次の【記述】の中の①から⑤までの()内に、狭義の共犯(教唆犯及び幫助犯)が成立するための要件に関する後記のAからDまでの各【見解】から適切なものを入れた場合、()内に入るものの組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。なお、一つの()内に二つ以上の見解が入る場合もある。

【記述】

(①)とする見解によれば、12歳の乙が、甲に唆されたことにより、V方から現金を盗んだという事例では、甲に窃盗罪の教唆犯が成立する可能性があるが、(②)とする見解によると、甲に窃盗罪の教唆犯が成立する余地がないことになる。また、甲が、故意のない乙を唆して、ある故意犯に当たる行為を実行させた場合、故意が構成要件の要素であるとすれば、(③)とする見解に立たない限り、甲には教唆犯は成立しないことになる。さらに、乙とVが殴り合っているのを発見した甲が、かねてからVに対する反感を持っていたことから、乙をしてVに怪我を負わせる意図で乙に木刀を渡したところ、乙がその木刀でVを殴って怪我を負わせたが、実は乙はVから突然襲われてやむを得ず殴り合いになったもので、乙には正当防衛が成立するという事案の場合、(④)とする見解に立てば、甲には傷害罪の幫助犯が成立する可能性があるが、(⑤)とする見解に立つと、甲には傷害罪の幫助犯は成立しないことになる。

【見解】

- A. 共犯者の固有の行為としての教唆・幫助行為があれば足り、被教唆者・被幫助者が犯罪を実行したか否かは問わない。
 B. 正犯が一定の行為を行ったことを要するが、その内容としては、正犯の行為が構成要件に該当すれば足りる。
 C. 正犯が一定の行為を行ったことを要するが、その内容としては、正犯の行為が構成要件に該当し、かつ、違法であることを要する。
 D. 正犯が一定の行為を行ったことを要するが、その内容としては、正犯の行為が構成要件、違法性及び責任を備えていなければならない。

1. ①A、B、C ②D ③A ④A、B ⑤C、D
 2. ①B、C、D ②A ③D ④B、C、D ⑤A
 3. ①A、B ②C、D ③A ④B、C、D ⑤A
 4. ①A、B、C ②D ③A ④C、D ⑤A、B
 5. ①A、B ②C、D ③D ④A、B ⑤C、D

No145

H19-6

共犯の要素従属性

正解

1

正答率

94%

() には順に、① = A、B、C、② = D、③ = A、④ = A、B、⑤ = C、D と入り、したがって、正解は肢 1 となる。

本問は実行従属性（従属性の有無）、及び要素従属性（従属性の程度）の理解を試す問題である。

実行従属性 { 共犯独立性説 (A)
 { 共犯従属性説……要素従属性 { 最小限従属性説 (B)
 { 制限従属性説 (C)
 { 極端従属性説 (D)

まず、正犯である乙は 12 歳であるから、刑事未成年者として責任能力を欠く (41 条)。そうすると、極端従属性説 (D) においては、窃盗罪の教唆犯が成立する余地は無いことになる (②)。これに対して、共犯独立性説 (A)、最小限従属性説 (B)、制限従属性説 (C) によれば窃盗罪の教唆犯が成立する可能性がある (①)。

次に、故意のない乙を唆して、ある故意犯にあたる行為を実行させた場合、故意が構成要件要素であるとすれば、乙の行為は故意を欠くから構成要件に該当せず、共犯独立性説 (A) によらなければ、甲には教唆犯は成立しないことになる (③)。

そして、乙には正当防衛 (36 条 1 項) が成立するという事案の場合、正当防衛が成立した場合は違法性が阻却される。そうすると、共犯独立性説 (A)、最小限従属性説 (B) によれば甲には傷害罪の幫助犯が成立する可能性がある (④) が、極端従属性説 (D)、制限従属性説 (C) によれば甲には傷害罪の幫助犯は成立しないことになる (⑤)。